

RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE.

A R R E S T

**nr. 189.705 van 22 januari 2009
in de zaak A. 71.846/XII-89.**

In zake : de NV GULDENBERG DATA ENGINEERING,
die woonplaats kiest bij
advocaten Ph. Coenraets en P. Luchie,
kantoor houdende te 1000 Brussel,
Terkamerenlaan 27

tegen :

het AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE
VLAANDEREN,
voorheen de VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ,
die woonplaats kiest bij
advocaat D. D'Hooghe,
kantoor houdende te 1000 Brussel,
Loksumstraat 25.

tussenkommende partij :

de NV TELE-ATLAS BELGIUM,
die woonplaats kiest bij
advocaten J. L. Stuyck en D. Lindemans,
kantoor houdende te 1000 Brussel,
Keizerslaan 3.

DE RAAD VAN STATE, XIIe K A M E R,

Gezien het verzoekschrift dat de NV Guldenberg Data Engineering op 9 december 1996 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van “de toewijzingsbeslissing van de Vlaamse Landmaatschappij aan NV Tele Atlas Data Gent, bij beslissing van de Raad van Bestuur van 9 oktober 1996, met betrekking tot het bestek OC-96/01 ‘Opdracht voor aanneming van leveringen. Digitaal vectorieel wegen- en spoorwegenbestand op middenschaalniveau voor het Vlaams en Brussels gewest’”;

Gelet op het arrest nr. 157.987 van 27 april 2006 waarbij de debatten worden heropend en het door de auditeur-generaal aan te stellen lid van het auditoraat ermede wordt belast het onderzoek van de zaak voort te zetten met betrekking tot de gegrondheid van het eerste middel en, in voorkomend geval, de ontvankelijkheid en gegrondheid van de overige middelen;

Gelet op het arrest nr. 177.749 van 11 december 2007 waarbij het eerste middel niet gegrond is bevonden, de debatten worden heropend en het door de auditeur-generaal aan te stellen lid van het auditoraat ermede wordt belast het tweede, derde en vierde middel te onderzoeken op hun ontvankelijkheid en hun gegrondheid;

Gezien het aanvullend verslag opgesteld door eerste auditeur J. Stevens;

Gelet op de kennisgeving van het verslag aan partijen en gezien de laatste memorie van de verzoekende partij;

Gelet op de beschikking van 22 juli 2008 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 7 oktober 2008;

Gehoord het verslag van kamervoorzitter D. Verbiest;

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. Van Parijs, die loco advocaten Ph. Coenraets en P. Luchie verschijnt voor de verzoekende partij, van advocaat N. Kiekens, die loco advocaat D. D'Hooghe verschijnt voor de verwerende partij, en van advocaat J. Honnay, die loco advocaat D. Lindemans verschijnt voor de tussenkomende partij;

Gehoord het eensluidend advies van eerste auditeur J. Stevens;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

OVERWEEGT WAT VOLGT :

De gegevens van de zaak

1. De verwerende partij schrijft een algemene offerteaanvraag uit voor een opdracht voor aanneming van leveringen. De opdracht strekt tot de levering van een digitaal vectorieel wegen- en spoorwegenbestand op middenschaalniveau voor het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het toepasselijke bestek voorziet in een “basisopdracht” en drie “opties” of aanvullende leveringen.

Het bestek (blz. 6) bepaalt als gunningscriteria, “in volgorde van afnemend belang” :

- “(1) De technische waarde van de te leveren bestanden en bijkomende bestanden, rekening houdend met de technische contractuele bepalingen, met inbegrip van de resultaten van de testen (40 %).
- (2) De volledige prijs, inclusief de prijs voor de 3 opties (40 %).
- (3) De kwaliteit van de voorziene dienstverlening, de kennisoverdracht, de documentatie en de ondersteuning (10 %).
- (4) De financiële en beroepswaarborgen (5 %).
- (5) De voorgelegde referenties m.b.t. gelijkaardige opdrachten en de specifieke problematiek (5 %)”.

Op 1 juli 1996 worden de offertes geopend. Er blijken vier inschrijvers een offerte te hebben ingediend, onder wie de verzoekende partij en de tussenkomende partij NV Tele-Atlas Belgium en het Nationaal Geografisch Instituut.

In een uitgebreide nota van 19 september 1996 vergelijkt de administratie de inschrijvingen.

Uiteindelijk wordt daarin de verzoekende partij telkens geklasseerd na NV Tele-Atlas Belgium, en na het Nationaal Geografisch Instituut. In het voorstel van beslissing wordt voor de eerste “optie” van NV Tele-Atlas Belgium gekozen.

De Raad van Bestuur van de verwerende partij neemt in zijn zitting van 9 oktober 1996 de bestreden beslissing, in navolging van het voornoemde voorstel waarnaar in de beslissing wordt verwezen.

De ontvankelijkheid

2. In het auditoraatsverslag wordt aangenomen dat uit het voormelde arrest nr. 177.749 moet worden afgeleid dat de exceptie van de verwerende partij betreffende de ontstentenis van belang bij het tweede, derde en vierde middel is verworpen. Meteen wordt de gegrondheid van de betrokken middelen onderzocht.

Na het auditoraatsverslag laat de verwerende partij aan de Raad van State weten dat zij geen laatste memorie indient.

In die omstandigheden wordt aangenomen dat de verwerende partij niet langer op haar exceptie aandringt. Gelet overigens op het feit dat hierna geen van de middelen gegrond wordt bevonden komt een onderzoek van en een uitspraak over het belang bij de middelen overbodig over.

De gegrondheid

Tweede middel

3.1. Het tweede middel wordt in het inleidend verzoekschrift gesteund op schending van “artikel 25A§1 juncto 42, §1 van het uitvoeringsbesluit overheidsopdrachten”. Daarbij stelt de verzoekende partij dat “de inschrijvingen van Tele-Atlas en in mindere mate Master, fundamenteel afwijken van de essentiële besteksbepalingen”. Zij ontwikkelt zulks in drie onderdelen.

3.1.1. In een eerste middelonderdeel wordt aangevoerd wat volgt :

“3.2.1. De gunningscriteria, vermeld in punt 1.9. van het bestek OC-96/01

Dat het eerste gunningscriteria, hebbende een gewicht van 40 %, de technische waarde betreft ‘van de te leveren bestanden en bijkomende bestanden, rekening houdende met de technische contractuele bepalingen, met inbegrip van de resultaten van de testen’

Dat het evaluatieverslag van de stuurgroep GIS-Vlaanderen, waarop de beslissing van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij geruggesteund is, uitdrukkelijk dient vast te stellen op blz. 6, derde alinea :

‘Het onvolledig zijn van de testbestanden van twee inschrijvers (Master en Tele Atlas) heeft voor gevolg gehad dat een aantal vergelijkende testen

niet of niet volledig konden uitgevoerd worden waardoor de beoordeling van de resultaten van de testen bemoeilijkt werd’;

Dat men echter meent dit te kunnen wegwuiven door de ene zinsnede : ‘Er werd nochtans vermeden om deze onvolledigheid te laten doorwerken in de quotering’;

Dat het echter vanzelfsprekend is dat de volledigheid van de testbestanden een essentieel element uitmaakt van de besteksvoorwaarden;

Dat het basiswerk van Flamme en Mathei ‘Praktische Commentaar Overheidsopdrachten’, nr. 55.3, uitdrukkelijk beklemtoont dat de term ‘technische waarde’ slechts een verzamelbegrip inhoudt dat nader moet worden omschreven;

Dat, in casu, het bestek uitdrukkelijk stelde hoe de technische waarde nader wordt omschreven, nl. door testbestanden die uiteraard volledig moeten zijn;

Dat, ten titel van overvloed, het bestek OC-96/01, in punt 1.11.2, blz. 8, punt 2, nog de volgende specificaties verschaft over de ‘testbestanden op diskette’ :

‘Deze testbestanden hebben betrekking op :

- de te leveren bestanden in het kader van de basisopdracht;
- de te leveren bijkomende bestanden in het kader van optie 1.

De testbestanden zullen ten minste betrekking hebben op het volledige gebied gelegen op de NGI-1/10000-cardbladen 11/8, 12/5, 18/6 en 18/7 voor wat betreft het bestand zoals bedoeld in de basisopdracht. Het testbestand voor wat betreft optie 1 zal betrekking hebben op het volledige grondgebied van carblad 18/6’;

Dat het essentieel karakter van de testbestanden derhalve uitvoerig zijn beklemtoond geworden door de woorden ‘ten minste’, ‘het volledige gebied’ en ‘het volledige grondgebied’;

Dat er geen discussie bestaat over het volkomen conform zijn van de testbestanden die verzoekster indiende;

Dat men zelfs in het evaluatieverslag van de stuurgroep GIS-Vlaanderen, twee alinea’s verder, moet vaststellen dat het gaat om een ‘erg volledig bestand’, ‘in verband gebracht met de strenge kwaliteitscontroles die RMS-India hanteert’ (de onderaannemer van verzoekster);

Dat het vaststellen dat Tele Atlas en Master een onvolledig testbestand binnenbrachten, er op zijn minst had toe moeten leiden dat de Vlaamse Landmaatschappij een essentiële tekortkoming diende vast te stellen in de binnengebrachte inschrijving, rekening houdende met de definitie van technische waarde in het bestek”.

In laatste memorie wordt daar nog aan toegevoegd :

“1. Volgens Mijnheer de Eerste Auditeur kan niet gesteld worden dat het afleveren van volledige bestanden voor alle kaartbladen een essentiële bestekbepaling uitmaakt.

In dit opzicht zou, volgens Mijnheer de Eerste Auditeur, door het leveren van een volledig bestand voor kaartblad 18/6 het doel van de vraag naar de bestanden bereikt zijn (nl. enerzijds het gebruik ervan voor het uitvoeren van een evaluatietest en anderzijds om te gelden als object van kwaliteitsverbintenis).

Zulke bewering is in tegenstrijd met het evaluatieverslag zelf van tegenpartij, hetwelk voorziet :

‘Het onvolledig zijn van de testbestanden van twee inschrijvers (Master en Tele Atlas) heeft voor gevolg gehad dat een aantal vergelijkende testen

niet of niet volledig konden uitgevoerd worden waardoor de beoordeling van de resultaten van de testen bemoeilijkt werd'

Tegenpartij toont dus in haar eigen evaluatie aan, dat zij ook, en eigenlijk zelfs vooral, het kwantitatieve aspect zeer essentieel vindt (en dit precies omdat nu juist het volledige karakter van de testbestanden een effectieve vergelijking van de offertes mogelijk maakt¹.

[...]

Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dus duidelijk dat het substantieel karakter van een bepaling van het bijzonder lastenboek dient beoordeeld [te] worden in het licht van het principe van de gelijkheid tussen de inschrijvers.

In dit geval, zoals volgt uit het evaluatierapport van de tegenpartij, heeft het onvolledig karakter van de testen van de gegevensbank, geen effectieve vergelijking toegelaten van de offertes m.b.t. de technische aspecten en werd het principe van het gelijkheidsbeginsel, gedurende het nazicht van de offertes, niet gerespecteerd.

Indien we nog zouden veronderstellen dat, zoals de Heer Auditeur schrijft : het leveren van een volledig bestand voor kaartblad 18/6 erop gericht is het door het bijzonder lastenboek nagestreefde doel te bereiken met name 'het uitvoeren van een evaluatietest' dan moet nog worden vastgesteld dat deze levering slechts gedeeltelijk het nagestreefde doel bereikt omdat, zoals tegenpartij zelf heeft gesteld 'een aantal vergelijkende testen niet of niet volledig konden uitgevoerd worden'.

Tegenpartij heeft echter in zijn lastenboek, verschillende keren het belang van deze tests benadrukt, tests die trouwens integraal deel uitmaken van de toewijzingscriteria van de offertes !²

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dus dat de beschikking van het bestek betreffende het afleveren van volledige bestanden voor vier bepaalde kaartbladen een substantieel karakter had en bijgevolg de schending van deze formaliteit van aard is om de regelmatigheid van de offerte van maatschappij Tele Atlas aan te tasten.

(1) Het is des te meer zo dat het onvolledig karakter van de testbestanden een invloed op de kwaliteit van het product heeft. Inderdaad, het testbestand eveneens de basis vormt voor de kwaliteitsverbintenis, die elke individuele inschrijver krachtens artikel 4.6.2. van het bestek diende te onderschrijven. Het feit dat de kwaliteit van het product, waartoe de individuele inschrijvers zich verbinden, deze is die over alle testbestanden wordt geleverd, impliceert dat de inschrijver die een onvolledig testbestand indient, uiteraard geen fouten kan maken in een testbestand dat niet gemaakt werd.

(2) Zie het artikel 1.9 van het bestek, dat voorziet :

'1.9. Gunningscriteria

De voordeligste offerte wordt bepaald, rekening houdend met volgende gunningscriteria in volgorde van afnemend belang.

(1) De technische waarde van de te leveren bestanden en bijkomende bestanden, rekening houdend met de technische contractuele bepalingen, met inbegrip van de resultaten van de testen [...] Volgens Mijnheer de Eerste Auditeur, zou het verzoekster blijkbaar 'voordelig uitgekomen zijn aangezien van bij de start niet meer dan 9 entiteiten toegang dienden te hebben tot de bestanden : de fasering qua aantal met een consequentie voor de prijs kwam overeen met de behoefte van tegenpartij'".

3.1.2. Het eerste gunningscriterium is de technische waarde van de te leveren bestanden en bijkomende bestanden, rekening houdend met de technische contractuele bepalingen, "met inbegrip van de resultaten van de testen".

In de eerste plaats kan uit de aangehaalde omschrijving niet worden afgeleid of er sprake is van een essentiële besteksbe­paling, waar het de woorden “met inbegrip van de resultaten van de testen” betreft.

Voorts bestaat er tussen partijen geen betwisting over het feit dat de tussenkomende partij enkel een volledig testbestand heeft afgeleverd voor kaartblad 18/6 maar niet voor de kaartbladen 11/8, 12/5 en 18/7.

Nu is in punt 1.11.2 (2) van het bestek inzake “Testbestanden op diskette” bepaald dat “de testbestanden ten minste betrekking [zullen] hebben op het volledige gebied gelegen op de NGI-1 : 10.000-kaartbladen 11/8, 12/5, 18/6 en 18/7”.

De vraag rijst aldus of door het genoemde verzuim een essentiële besteksbe­paling geschonden is. In dat verband verwijst de verwerende partij terecht naar de punten 4.6.1 en 4.6.2 van het bestek. In punt 4.6.1 (“Evaluatietesten”) wordt bepaald dat “elke inschrijver bij zijn inschrijving aan de opdrachtgever een testbestand ter beschikking [zal] stellen van een proefgebied waarvan de ligging omschreven is onder 1.11.2 (2)” en dat “dit bestand in de eerste plaats [zal] gebruikt worden voor het uitvoeren van een evaluatietest om de kenmerken van het aangeboden wegenbestand te controleren en te evalueren ten opzichte van de specificaties van onderhavig bestek en de bij de inschrijving ingediende specificaties”: in de eerste aangehaalde volzin wordt verwezen naar de bepaling van 1.11.2 (2) en in de tweede aangehaalde volzin wordt het doel van de vraag tot het afleveren van een bestand beschreven, namelijk om het in de eerste plaats te gebruiken voor het uitvoeren van een evaluatietest, hetgeen kadert in de kwaliteitscontrole die hoort bij het eerste gunningscriterium.

In punt 4.6.2 van het bestek (“Kwaliteitsverbintenis”) wordt bepaald dat het ingediende testbestand zal gelden als object van kwaliteitsverbintenis die de inschrijver op zich neemt, waarmee hij de minimumkwaliteit van het te leveren wegenbestand garandeert.

Met de verwerende partij wordt aangenomen dat door het leveren van een volledig bestand voor kaartblad 18/6 het doel van de vraag naar de bestanden bereikt is, namelijk enerzijds het gebruik ervan voor het uitvoeren van een evaluatietest en anderzijds om te gelden als object van kwaliteitsverbintenis.

Hieruit vloeit voort dat de verwerende partij terecht het afleveren van volledige bestanden voor alle kaartbladen niet als een essentiële besteksbepaling aanmerkte. Het middelonderdeel wordt niet aanvaard.

3.2.1. In een tweede middelonderdeel doet de verzoekende partij gelden wat volgt :

“3.2.2. Het eigendoms- en gebruiksrecht ten gunste van de Vlaamse Landmaatschappij, opgenomen in 2.4.1. van het bestek OC-96/01

Dat het bestek uitdrukkelijk handelt over een ‘niet-exclusief eigendoms- en gebruiksrecht van onbeperkte duur op alle in het kader van deze opdracht geleverde bestanden’, ten voordele van de Vlaamse Landmaatschappij;

Dat verder wordt gepreciseerd dat de Vlaamse Landmaatschappij het bestand ter beschikking zal stellen overeenkomstig het samenwerkingsverband van GIS-Vlaanderen aan ‘alle geledingen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse openbare instellingen, en alle andere besturen, organisaties en instellingen die formeel tot het GIS-Vlaanderen toetreden’;

Dat het dan ook onaanvaardbaar is dat Tele Atlas, in diens offerte, slechts negen legale entiteiten toelaat, zodat het gebruik geenszins onbeperkt is;

Dat het laatstvermelde kan worden afgeleid uit de toewijzingsbeslissing van de Vlaamse Landmaatschappij dd. 9 oktober 1996 welke uitdrukkelijk vaststelt dat ‘het bestand kan worden gebruikt door 8 juridische entiteiten en de Vlaamse Landmaatschappij’;

Dat dit echter flagrant in tegenstrijd is met de bestekbepalingen, zoals hierboven weergegeven en de inschrijving van Tele Atlas, enkel reeds om die reden, had moeten geweerd zijn;

Dat verzoekster daarenboven heeft vernomen dat Tele Atlas zelfs geen eigendoms- en gebruikersrecht zou kunnen verlenen voor diens basisofferte Vlagisnet;

Dat het niet-conform zijn van de inschrijving van Tele Atlas ten opzichte van essentiële bestekbepalingen derhalve eventueel nog veel omvangrijker is dan hierboven weergegeven;

Dat de gunning echter uiteindelijk betrekking heeft gehad op de suggestie, zijnde Street Net, waarbij men slechts een beperkt aantal entiteiten een ‘niet-exclusief eigendoms- en gebruikersrecht van onbeperkte duur’ kan verlenen”.

In laatste memorie luidt het :

“Mijnheer de auditeur preciseerd :

‘Indien van bij de start meer dan 9 entiteiten toegang dienden te hebben en zelfs het maximum aantal, voldeed het voorstel van tussenkomende partij ook, kon het voorstel gehonoreerd worden en kon de prijs daarvan berekend worden’.

Door zulke bewering, erkent mijnheer de eerste Auditeur dat een onbeperkt gebruik van de geleverde bestanden niet noodzakelijk zal toegelaten worden aan tegenpartij tijdens de uitvoering van de opdracht.

[...]

Er is dus sprake van een schending van het artikel 2.4.1. van het bestek en dit in tegenstelling met wat mijnheer de eerste auditeur beweert.

Het feit dat het voorgestelde³ systeem eigenlijk voordelig zou zijn voor verzoekster -hetgeen trouwens nergens wordt aangetoond- houdt niet in dat

tegenpartij kan afwijken van de bepalingen van het door haar opgestelde bijzonder lastenboek.

Het past, hieromtrent, om eraan te herinneren dat het bijzonder lastenboek tot doel heeft om, in tempore non suspecto, de kandidaten te informeren over de verwachtingen (en dus de noden) van de toewijzende overheid omtrent de overheidsopdracht die zij wenst toe te wijzen. Het is derhalve aan diezelfde overheid niet toegelaten om, in de loop van de toewijzingsprocedure van de overheidsopdracht terug te komen op haar verwachtingen derwijze dat het gelijkheidsprincipe tussen inschrijvers compleet wordt miskend. Dit is nochtans precies wat tegenpartij inzake heeft gedaan.

(3) Volgens de termen van mijnheer de eerste auditeur, ‘het moduleren van het ter beschikking stellen van de bestanden van de suggestie Streetnet qua aantal gekoppeld aan een startprijs voor 8 entiteiten en het Ondersteunend Centrum, vermeerderd met een forfaitaire prijs voor elke bijkomende entiteit tot een plafond’”.

3.2.2. Hetgeen de tussenkomen partij voorgesteld heeft, is de verwerende partij blijkbaar voordelig uitgekomen aangezien niet reeds van bij de start meer dan 9 entiteiten toegang dienden te hebben tot de bestanden : de fasering qua aantal met consequentie voor de prijs kwam overeen met de behoefte van de verwerende partij. Indien van bij de start meer dan 9 entiteiten toegang dienden te hebben en zelfs het maximum aantal, voldeed het voorstel van de tussenkomen partij ook; het kon immers worden gehonoreerd en de prijs daarvan kon worden berekend.

Het moduleren van het ter beschikking stellen van de bestanden van de suggestie Streetnet qua aantal gekoppeld aan een startprijs voor 8 entiteiten en het Ondersteunend Centrum, vermeerderd met een forfaitaire prijs voor elke bijkomende entiteit tot een plafond, kan aldus niet worden aangemerkt als een schending van het door de verzoekende partij ingeroepen punt 2.4.1. van het bestek.

Het middelonderdeel wordt niet aanvaard.

3.3.1. In een derde middelonderdeel betoogt de verzoekende partij wat volgt :

“3.2.3. De omschrijving van het vereiste wegenbestand met de minimale attribuut informatie, zoals weergegeven in punt 4.2.1. en 4.2.2.1. van het bestek OC-96/01

Dat, allereerst, punt 4.2.1. van het bestek de minimale objecten opneemt voor het wegen- en spoorwegenbestand;

Dat onder de eerste rubriek ‘wegen’ uitdrukkelijk de ‘afsluiting van wegen, straten en paden’ wordt beklemtoond;

Dat de daaropvolgende besteks bepaling 4.2.2.1. voorschrijft :

‘Wat betreft het wegenbestand, zoals bedoeld in de basisopdracht (in het vet gedrukt) is voor elk lijnsegment minimaal volgende attribuut informatie opgenomen :

- (1) fysische wegklasse : - autoweg
- weg met verharding van 7 m of breder
- weg met verharding smaller dan 7 m
- moeilijk berijdbare weg
- aardeweg/niet-verharde weg
- pad
- brandlaan
- (2) liggingsskenmerken : - brug (+orde)
- viaduct (+ orde)
- gelijkgronds
- tunnel
- ferry
- veer’;

Dat het evaluatieverslag van stuurgroep GIS-Vlaanderen op blz. 17, eerste alinea, dient vast te stellen dat de uiteindelijk weerhouden suggestie ‘Street Net’, ‘in vergelijking tot de andere inschrijvingen op basisopdracht, minder weglengte’ inhoudt;

Dat men zelfs preciseert : ‘Het belang van het feit dat Street Net ca. 40 % minder weglengte bevat, moet gerelativeerd worden...’;

Dat men echter uit het oog verliest dat deze relativering ertoe leidt dat men een essentiële bepaling van het bestek schendt”.

Vastgesteld wordt dat de verzoekende partij het feit dat Streetnet “ca. 40 % minder weglengte omvat” in haar verzoekschrift poneert als zijnde een schending van een essentiële besteksbe­paling, blijkbaar van het -uitgebreide-punt 4.2.2.1 van het bestek, zonder te verduidelijken wat die essentiële besteksbe­paling juist is en hoe ze dan wel zou zijn geschonden. Alleen reeds om die reden is het middelonderdeel niet ontvankelijk en moet het worden verworpen.

In haar memorie van wederantwoord gaat de verzoekende partij weliswaar uitgebreid in op de kwestie en tracht zij haar gelijk te halen door te citeren uit en zich te steunen op de voormelde evaluatienota van 19 september 1996, hoewel zij die nota reeds van bij het opstellen van haar verzoekschrift in haar bezit had, en deze er als stuk IV aan toevoegde. Hetgeen daaromtrent wordt aangevoerd in de memorie van wederantwoord is dan ook een niet ontvankelijke nieuwe invulling van het middel.

Het derde middelonderdeel en dienvolgens het tweede middel in zijn geheel worden niet aanvaard.

Derde middel

3.4.1.

Het derde middel luidt in het inleidend verzoekschrift :

“3.3. Bij het niet-weerhouden van de eerste middelen, staat het op zijn minst vast dat de keuze van NV Tele Atlas kennelijk onredelijk is door de vastgestelde verkeerde vergelijking (3.1.) en het geenszins eerbiedigen van de essentiële bestekbepalingen (3.2.)

Dat het slechts een marginale toetsing vergt van uw Raad van State om vast te stellen dat men kost wat kost de opdracht wenste te gunnen aan NV Tele Atlas, conform de geruchten die ook de ronde deden en men hiervoor niet terugschrikt om de bepalingen van het bestek niet meer als essentieel te beschouwen of, elke objectieve vergelijking met de uiteindelijk suggestie van NV Tele Atlas uit te sluiten;

[...]

Dat immers de beoordeling van het luik ‘volledigheid’ kennelijk onredelijk is, aangezien het product van verzoekster als het meest volledige wordt gekwalificeerd, maar slechts 8 op 10 krijgt, waar het minder volledige product van Tele Atlas 9 op 10 krijgt;

Dat het evaluatieverslag op pagina 6 (‘volledigheid van het wegennet’) stelt :

‘De firma Guldenberg leverde in relatie tot het uitgangsmateriaal van de digitalisatie (1 : 10.000 top-kaarten van NGI), een erg volledig bestand (in totaal 1978 km weg op een oppervlakte van 292 km², 6,77 km/km²). Deze volledigheid kan in verband gebracht worden met de strenge kwaliteitsnormen die RMS-India hanteert.

(...)

Tele Atlas komt voor wat betreft kaartblad 18/6 op dezelfde totale lengte als Guldenberg. Voor wat betreft de andere kaartbladen nochtans zijn de waarden t.o.v. Guldenberg resp 69 %, 56 % en 58 % (...)

Dat verzoekster reeds sub 3.2.3. aantoonde dat ‘Streetnet’ 40 % minder weglengte bevat;

Dat het evaluatiebestand in verband met ‘Streetnet’ verdergaat :

‘Volledigheid

‘Streetnet’ heeft, in vergelijking tot de andere inschrijvingen op de basisopdracht, minder weglengte.’;

Dat de Vlaamse Landmaatschappij op kennelijk onredelijke wijze dit substantiële gebrek minimaliseert :

‘Het belang van het feit dat ‘Streetnet’ ca 40 % minder weglengte bevat, moet gerelativeerd worden in het licht van het gebruik van het skeletbestand.

Deze 40 % minder weglengte betreffen in hoofdzaak veldwegen, boswegen en paden zoals ze op de topografische kaarten zijn opgenomen. Deze wegen werden opgenomen in het uitgeschreven bestek omdat deze kunnen dienstig zijn voor toepassingen waarbij het skeletbestand als ruimtelijk skelet gebruik wordt. Het zal slechts incidenteel voorkomen dat aan deze kleine wegen en paden bijkomende attributuinformatie wordt gekoppeld.

Voorlopig kan de ruimtelijke skeletfunctie van het skeletbestand overgenomen worden door de rasterbestanden zoals ze op dit moment ter beschikking komen van het GIS-Vlaanderen.

Er moet wel opgemerkt worden dat naast de wegen in het ‘Streetnet’-bestand een aantal bijkomende object-thema’s zijn opgenomen : deelgemeenten, statische sectoren, water, parken, bebouwde kommen’.

Dat verzoekster reeds sub 3.2.1. en 3.2.3. aantoonde dat dit een miskennis uitmaakt van de essentiële bestekbepaling van art. 4.2.2.1;

Dat uit deze bestekbepaling, reeds geciteerd sub 3.2.3., blijkt welk een belang aan een gedetailleerde spoorweg- en gewone wegweergave wordt gehecht;

Dat het bestek verder luidt op p. 16 (artikel 4.2.1.) :

‘(...)

Minimaal moeten volgende objecten opgenomen worden :

(1) Wegen :

De aslijnen van wegen, straten en paden, zoals voorgesteld op de topografische kaarten, 1 : 10.000, van het Nationaal Geografisch Instituut, met aanduidingen van de kruisingen en aansluitingen (...)’ [...]

Dat het dan ook volledig ondenkbaar is dat de quoterings voor volledigheid van Tele Atlas (9) en verzoekster (8) op een objectieve en redelijke basis is tot stand gekomen, indien men rekening houdt met de hierboven aangetoonde fundamentele tekortkomingen bij eerste verweerster”.

3.4.2. Daargelaten opnieuw de vraag of dit middel voldoende duidelijk de geschonden rechtsregel omschrijft, hetgeen de verwerende partij betwist, dient te worden vastgesteld dat het derde middel gesteund is op het eerste middel én het tweede middel : het eerste middel is echter in voormeld arrest nr. 177.749 reeds ongegrond bevonden en het tweede middel is hiervoor niet aanvaard. Dienvolgens dient dan ook het derde middel als niet gegrond te worden aangemerkt.

Vierde middel

3.5.1. In een vierde middel voert de verzoekende partij aan wat volgt :

“Schending van art. artikel 44, vijfde lid van het K.B. van 22 april 1977

Dat verzoekster wijst op de mogelijkheid die door artikel 44, vijfde lid van het K.B. van 22 april 1977 wordt geboden aan de opdrachtgever, die vooraleer de opdracht te gunnen, met de kandidaat-inschrijvers in contact kan treden om de inhoud van offerte te preciseren of ... aan te vullen”.

Zij betoogt nader dat zulks het geval had moeten zijn inzake een niet door het bestek vereist onderhoudscontract en een doorgroeiscenario, voorgesteld door de gekozen inschrijver.

3.5.2. Artikel 44, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, bepaalt hetgeen volgt :

“In elk geval treedt het bestuur slechts in contact met de kandidaten indien zij de inhoud van hun offerte moeten preciseren of aanvullen”.

Deze bepaling is niet bedoeld om inschrijvers, die geen suggesties hebben ingediend, na de opening van de offertes, uit te nodigen en de kans te geven

suggesties in te dienen om reden dat één van de inschrijvers dergelijke suggesties heeft ingediend.

Het vierde middel is niet gegrond.

4. Geen van de door de verzoekende partij aangevoerde middelen is gegrond.

**OM DIE REDENEN
BESLIST DE RAAD VAN STATE :**

Artikel 1.

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2.

De kosten van de vordering tot schorsing en van het beroep tot nietigverklaring, bepaald op 99,16 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

De kosten van de tussenkomst, bepaald op 74,37 euro, komen ten laste van de tussenkomende partij.

Het door de tussenkomende partij teveel gekweten zegelrecht van 49,59 euro dient haar te worden terugbetaald

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op tweeëntwintig januari 2009, door de XIIe kamer, die was samengesteld uit :

de HH.	D. VERBIEST,	kamervoorzitter,
	J. LUST,	staatsraad,
	G. VAN HAEGENDOREN,	staatsraad,
Mevr.	S. DOMS,	griffier.

De griffier,

De voorzitter,

S. DOMS.

D. VERBIEST.